

1500362-49.2021.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... um efetivo envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes. Com efeito, não há motivos para crer que esteja falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500362-49.2021.8.26.0144 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500362-49.2021.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270219/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 1238/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2270219 -

DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELISSON HENRIQUE MOREIRA VIANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

WELISSON HENRIQUE MOREIRA VIANA, qualificado às fls. 07, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 04 de outubro de 2021, por volta das 10h40min, nas proximidades da Rua Mato Grosso, Parque Industrial, nesta Cidade e Comarca de Conchal, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 36 (trinta e seis) porções de crack, com peso aproximado de 7,6g (sete gramas e seis decigramas), e 10 (dez) porções de maconha, pesando cerca de 7g (sete gramas).

Notificado às fls. 62, o acusado apresentou defesa prévia às fls. 63/66.

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fl. 73/75).

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

A d. Representante do Ministério Público manifestou-se oralmente, conforme gravação audiovisual.

A i. Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a figura do art. 33, §3º da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa vem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 18/21, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08, pelo laudo de constatação de fls. 13/14, indicador de que o acusado trazia consigo 36 (trinta e seis) porções de crack, com peso aproximado de 7,6g (sete gramas e seis decigramas), e 10 (dez) porções de cocaína, pesando cerca de 7,1g (sete gramas e um decigrama). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 98/100, está comprovado que a substância apreendida com o acusado era "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil".

Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida em juízo, a testemunha policial militar José Nilson Fernando Gerotto Calderari disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, no cruzamento da rua Piauí com a rua Mato Grosso, quando visualizou duas pessoas, posteriormente identificadas como Welisson e Igor. Welisson soltou algo no chão e saiu andando. Foi abordado cerca de 02 (dois) metros de distância do objeto que ele havia soltado. Verificaram que era uma meia, que continha 36 porções de crack e 10 porções de cocaína. Em revista pessoal, encontraram R\$50,00 (cinquenta reais) na mão de Igor e R\$33,00 (trinta e três reais) em suas vestes íntimas. Às perguntas da acusação, não soube especificar onde estavam as porções de cocaína, pois a abordagem foi feita por seu colega de farda Alves. Às perguntas da Defesa, respondeu que havia outras pessoas no local, mas por ter visualizado o momento que Welisson dispensou o objeto, fez a abordagem diretamente.

Ouvido apenas na fase inquisitorial, Igor Ednei Costa dos Santos disse que estava descendo para ir até a Padaria junto com seu irmão Roberto e, em dado momento, Welisson passou com um baseado e o chamou para fumarem juntos. Afirmou que ele não vendeu a droga, apenas fez convite para fumarem juntos. Em seguida, estava junto com Welisson quando a Polícia Militar realizou a abordagem. Em poder do depoente estava com um aparelho celular e R\$44,00. Acrescentou que Welisson foi abordado, mas não viu nada em poder dele, sendo que Welisson engoliu o baseado dele. Reiterou que a Polícia Militar abordou todos que estavam no local, mas o depoente não viu drogas em poder de Welisson, apenas a que ele estava fumando.

Em solo policial, o réu Welisson Henrique Moreira Viana disse que foi despejado sábado e não foi trabalhar. Estava passando pela Rua Mato Grosso e avistou seu amigo Igor. Ele pediu uma droga para fumarem juntos, momento em que a viatura apareceu. O declarante engoliu a droga. Afirmou que foi agredido pelo Policial Militar Calderari com tapas na cara, chutes e socos, mas não ficou lesionado. Afirmou que só tinha um baseado, não tinha dinheiro e que desconhece as drogas apresentadas pela Polícia. Negou envolvimento com o tráfico de drogas.

Interrogado em juízo, o acusado disse que estava passando pelo local, fumando um baseado de maconha e ofereceu para seu colega Igor. Quando a viatura apareceu, sua reação foi de tentar apagar o baseado e engolir o restante. Disse que estava sendo perseguido pelo policial, que lhe abordou e agrediu. Afirmou que foi conduzido para averiguação. Disse que o policial vasculhou o local da abordagem, mas não lhe informou sobre a descoberta das drogas, que somente foram apresentadas na delegacia. Às perguntas da Defesa, respondeu que é usuário de maconha.

Diante da prova oral produzida, tenho que a versão apresentada pelo réu de que é apenas usuário de entorpecentes, se revela isoladas do acervo probatório. De outra parte, a palavra do policial militar, servidor público ouvido sob o crivo do contraditório, é coerente e está em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a destinação da droga apreendida, tendo em vista a variedade e a forma de acondicionamento, se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade do depoimento prestado pelo policial, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846)."

Ademais, o relato está amparado pela apreensão material da droga, fracionada em porções típicas do comércio ilegal, evidenciando um efetivo envolvimento do acusado com o tráfico ilícito de entorpecentes. Com efeito, não há motivos para crer que esteja falseando a verdade apenas para incriminar um inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014)."

Acrescento que o depoimento da testemunha Igor, em fase inquisitorial, não infirma a dinâmica dos fatos, visto que se limitou a dizer que não viu as drogas em poder de Welisson.

Por fim, afasto a pretensão de desclassificação para o delito do artigo 33, §3º, LD, vez que o uso compartilhado de eventual cigarro de maconha, que o acusado supostamente engoliu, não descaracteriza o crime de tráfico caracterizado pela conduta de trazer consigo as drogas apreendidas, consistentes em crack e cocaína. É pacífica a jurisprudência no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico não é necessário que o acusado seja colhido comercializando a substância entorpecente, bastando, apenas, a comprovação de sinais indicativos do exercício da atividade delituosa. É o que se vê do seguinte excerto extraído do julgamento da Apelação nº 0000166-49.2013.8.26.0334, 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. PENTEADO NAVARRO, j. 26 de junho de 2014:

"a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico (cf. Vicente Greco

Filho e João Daniel Rossi, Lei de Drogas Anotada, 1ª ed., Saraiva, 2007, art. 33, nº 4, pág. 81; RTJ, 149/521; RT, 727/478, 747/642, 750/590, 789/536, 793/576, 793/727, 807/597, 810/578 e 831/614).

Daí segue ser dispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando a prova do conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) envolvendo o agente acusado.

Certa, pois, a condenação do réu nos termos da denúncia, resta, enfim, a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isentem de sanção.

Passo à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase, a pena-base deve ser aumentada em decorrência de seus maus antecedentes, consoante se verifica por meio da leitura de sua folha de antecedentes as fls. 23/25, indicando a existência de duas condenações transitadas em julgado, das quais uma será usada como reincidência para não configurar bis in idem. Ressalte-se que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em caso de condenados multirreincidentes, é possível a exasperação da pena com base em mais de uma circunstância judicial e ainda agravar a pena pela reincidência, desde que para cada vetorial seja considerada uma condenação distinta. Neste sentido: "Hipótese em que, presente mais de uma condenação definitiva contra o paciente, a valoração desfavorável dos antecedentes, da personalidade e da conduta social, com lastro em condenações distintas, não enseja coação ilegal." (HC 309.114/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016). Por esses termos, para exasperar a pena, em primeira fase, considero a condenação no Processo nº 1500166-50.2019.8.26.0144 da Vara Única de Conchal. No mais, as demais circunstâncias são neutras, de modo que a pena-base deve ser aumentada em 1/8 (um oitavo), resultando em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão e pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, necessário que se leve em consideração que o acusado é reincidente, conforme evidencia a folha de antecedentes juntada aos autos que indica a condenação no Processo nº 0001233-32.2016.8.26.0144 da Vara Única de Conchal. Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes. Assim, majoro a pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto), fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento a considerar. Quanto às causas de diminuição de pena, em que pese seja o réu reincidente, considero que as especificidades da prisão em flagrante não evidenciam que ele, de fato, integra organização criminosa. Assim, tenho que as circunstâncias do caso concreto permitem excepcionalmente a aplicação do redutor do art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06, em fração mínima da margem legal. Assim, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto), definindo a pena final em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa.

À míngua de outros elementos, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente à data do fato.

Em vista da reincidência e considerando que o réu estava em cumprimento de pena (Processo nº 1500166-50.2019.8.26.0144, fl. 24) quando foi flagrado novamente na prática do ilícito, tenho que o único regime compatível e que atende ao binômio da necessidade/suficiência neste caso é o fechado.

Ausentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, CP).

Em que pese a constitucionalidade do previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de determinar a detração neste momento processual, haja vista a ausência de elementos a um seguro decidir quanto ao requisitos subjetivos, situação a ser melhor analisada em sede de execução penal.

Posto isso, julgo PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu WELISSON HENRIQUE

MOREIRA VIANA, qualificado às fls. 07, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, no cumprimento da pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa, fixados estes no mínimo legal.

Condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais, no montante de 100UFESP's, nos moldes do artigo 4.º, § 9.º, da Lei Estadual 11.608/03.

Não se permite ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, eis que desfavoráveis as condições subjetivas e presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, tal qual previsão dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não por outra razão aguardou ao trâmite da instrução encarcerado. Já expedido mandado de prisão em desfavor do réu, expeça-se o ofício de recomendação.

Com o trânsito em julgado: 1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP); 3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84); 4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 6) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe

Conchal, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA